

1514815-88.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fernando Augusto Andrade Conceição

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 14ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/03/2022

... e momentos diferentes. Nestes termos:

Tráfico de entorpecentes e Associação para o tráfico -Agentes surpreendidos trazendo consigo, para fins de tráfico, 3.026,50 gramas de cocaína em pó e 1.448,7 gramas de maconha - Conjunto probatório desfavorável aos réus alicerçado em depoimentos policiais verossímeis demonstrando tanto o tráfico como a união estável ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

14ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1514815-88.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1514815-88.2021.8.26.0228

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIZ HENRIQUE DUARTE BARBOSA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernando Augusto Andrade Conceição

Vistos.

Luiz Henrique Duarte Barbosa, qualificado nos autos na fl. 21, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº. 11.343/06, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, porque no dia 16/junho/2021, por volta das 22h30, em situação de fragilidade social decorrente de calamidade pública, na Rua Gita, altura do nº 74, Itaquera, nesta comarca, previamente ajustado e com unidade de desígnios com o adolescente Igor Ferreira de Matos, trazia consigo, para fins de comercialização, fornecimento e entrega a consumo de terceiros, drogas consistentes em 328 invólucros plásticos contendo substância Tetrahydrocannabinol, vulgarmente conhecida como maconha, com peso

líquido de 617,2g e 16 frascos contendo 120ml de Tricloroetileno, vulgarmente conhecido como lança-perfume, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, em desacordo com determinação legal e regulamentar. Consta na denúncia que, nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, Luiz Henrique se ajustou com o adolescente infrator Igor, este com 15 anos de idade, com a finalidade de praticarem o comércio de drogas; ocorreu que, policiais militares em patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, conhecido ponto de comercialização de entorpecentes, avistaram o indiciado e o menor em atitude suspeita e deliberaram por realizar a sua abordagem, isto porque, ao notar a presença policial, o acusado e o menor começaram a correr; após breve perseguição, Luiz Henrique e Igor foram capturados pelos milicianos; em busca pessoal foram localizadas as drogas acima mencionadas no interior de uma sacola plástica que o indiciado trazia consigo; com o adolescente foi encontrada a quantia de R\$618,00; questionados informalmente, o réu confessou a prática do tráfico de entorpecentes.

A denúncia (fls. 99/101) veio acompanhada do Inquérito Policial (fls. 01/95), sendo a peça acusatória recebida em 19/julho/2021 (fls. 116/117). Notificado/citado (fl. 152), o réu Defesa Preliminar (fls. 113/114),

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas (áudio - audiência virtual sistema Teams) e o denunciado interrogado ao final (áudio - audiência virtual sistema Teams).

Nas suas considerações finais, o Ministério Público requereu a procedência da ação nos exatos termos da denúncia, com o afastamento da agravante relativa a calamidade pública; a Defesa pugnou pela absolvição em razão da fragilidade probatória; em caso de condenação, requereu a aplicação da pena no mínimo legal, reconhecendo-se todos os benefícios a favor do réu.

O Laudo de Constatação Prévia encontra-se nas fls. 12/15; o de Exame Químico Toxicológico nas fls. 110/112 e o Auto de Exibição e Apreensão das substâncias entorpecentes está nas fls. 16/17.

É o relatório.

Decido.

Ao término da instrução, verificou-se que os fatos narrados na exordial restaram comprovados, razão pela qual a ação deve ser julgada a favor da Justiça Pública. Em solo policial, o denunciado Luiz negou a autoria delitiva, afirmou ser usuário de drogas (fl. 11).

Interrogado em Juízo, o acusado Luiz Henrique Duarte Barbosa, 22 anos, negou a acusação; no dia em questão, desceu até o local para adquirir maconha, por ser usuário; se deparou com a polícia e os traficantes correram, sendo o interrogando detido; a bolsa com as drogas foi deixada pelos traficantes; não é verdade que a bolsa verde estava na mão do interrogando; não disse para o delegado que estava naquele local junto com a pessoa que ficavam de campana, como constou na fls. 11; não conhecia o infante Igor Ferreira, mas apenas de vista, pois eram da mesma região; (áudio sistema SAJ).

Vejamos a prova do contraditório.

A testemunha Washington Schast Batista disse que abordou os dois em local conhecido pela mercância ilícita, sendo que com o réu encontrou uma sacola contendo maconha e lança perfume; o menor Igor tinha dinheiro nos bolsos; ambos confessaram informalmente a venda ilícita (áudio sistema SAJ).

A testemunha Maciel de Melo Santos, policial militar, ratificou, na íntegra, o depoimento do colega de farda, em especial, o local, conhecido ponto de venda; se deparou com os dois conversando assim que adentrou na rua; eles correram, mas foram abordados; o réu segurava uma sacola verde contendo maconha e lança perfume, além de um aparelho celular; com o menor encontrou R\$618,00 nos bolsos, além de celular; indagados, ambos confessaram o tráfico de drogas (áudio sistema SAJ).

Assim, como se vê, com o término da instrução, ficou comprovado que todo o entorpecente apreendido pertencia ao réu Luiz Henrique e ao comparsa, o menor Igor. O relato das testemunhas de acusação, somadas ao Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Apreensão, Laudo de Constatação Prévia e Exame Químico Toxicológico, tudo aponta no sentido de que a versão apresentada pelos policiais é a verdadeira, eis que encontra simetria com as demais provas dos autos.

Com sua conduta, o réu se enquadra em, pelo menos, um verbo do tipo previsto no artigo 33 da lei especial: trazer consigo.

Destarte, verifica-se que a ação penal procede.

De fato, os depoimentos dos policiais foram claros, serenos e seguros, dando conta da apreensão em poder do acusado, de razoável quantidade de substância entorpecente, o suficiente a denotar o intuito da traficância.

Também ficou evidente a participação do infante Igor, cúmplice do acusado na venda das drogas em via pública.

A materialidade está estampada no Boletim de Ocorrência (fls. 03/06), no Auto de Exibição e Apreensão (fls. 16/17), no Auto de Constatação Prévia (fls. 12/15) e no Exame Químico Toxicológico (fls. 110/112).

Este último demonstra que as substâncias apreendidas realmente eram maconha e cloreto de metileno.

Em que pese à insurgência da Defesa, a traficância restou devidamente caracterizada e comprovada.

Como visto, os depoimentos dos policiais ouvidos em Juízo são coerentes e harmônicos e traduzem a certeza de que o réu, efetivamente, trazia consigo, dentro de uma sacola, razoável quantidade de maconha e lança-perfume, quando foi flagrado pelos agentes.

Portanto, restou claro que os policiais prenderam o acusado em flagrante em plena conduta típica, apreendendo em seu poder toda a maconha e lança-perfume encontrados.

Bem sabemos, como já dito acima, que incide nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, aquele que é detido com expressiva quantidade de substância tóxica.

No caso concreto, a droga estava sendo trazida, para entrega a consumo de terceiros, pelo acusado em pela via pública, instante em que foi abordado por policiais militares, o que configura tráfico e não uso de drogas.

Assim, uma vez que o réu foi surpreendido tendo consigo substância entorpecente, não se pode falar em guarda para consumo próprio, com a consequente desclassificação para o delito previsto no artigo 28, da Lei 11.343/06, mas sim em tráfico ilícito.

Certo é que, a só quantidade de droga, ainda que razoável, não define, por si só, a condição de traficante. Mas no presente caso, verifica-se que o réu foi flagrado trazendo consigo toda a maconha e lança-perfume apreendidos dentro de uma sacola. É sabido que se tem reiteradamente decidido que para a caracterização do delito previsto no artigo 33, não se faz necessário seja o infrator colhido no próprio ato da venda da mercadoria proibida. Tratando-se de crime de mera conduta, ter em depósito, guardar, transportar, trazer consigo, não importa a modalidade, forçoso reconhecer-se à configuração do crime em tela.

Ademais, por importante, mister se faz atentar para a natureza e a quantidade da substância apreendida (617,2g de maconha e 120 ml de lança-perfume), o local (dentro de uma sacola) e as condições em que se desenvolveu a atividade delituosa (policiais em patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, conhecido ponto de comercialização de entorpecentes, avistaram o réu e o menor em atitude suspeita e resolveram pela abordagem, ocasião em que ambos, ao notar a presença da viatura, começaram a correr, porém foram abordados e as drogas localizadas).

Outrossim, não há que desmerecer os depoimentos dos policiais - ouvidos como testemunhas - tão só pelo fato de serem eles integrantes da Polícia.

Tal significaria preconceito odioso e inaceitável, caracterizando mesmo clara discriminação profissional que não tem qualquer respaldo jurídico.

Observe-se que, a Defesa nada comprovou contra a honradez e honorabilidade dos policiais ouvidos como testemunhas neste processo, nem mesmo que tivessem eles qualquer razão escusa para pretenderem prejudicar o acusado.

Assim, seus depoimentos não de ser prestigiados, em especial porque apresentam contornos de verossimilhança, estão conforme o conjunto das provas e, ademais, como já dito, são coerentes entre si, formando um todo harmônico e lógico.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de entorpecentes - Recurso da defesa - Preliminar de

cerceamento de defesa - Inocorrência - Rejeitada - Absolvição - Materialidade e autoria demonstradas - Acusada surpreendida mantendo em depósito drogas para imediata distribuição - Depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pela diligência - Validade - Contradições insignificantes e incapazes de ensejar a absolvição - Pena base alterada, mas sem reflexo na pena final - Redutor negado, mercê da expressiva quantidade de drogas apreendidas - Regime mantido em razão da gravidade da conduta - Apelo improvido. (TJSP; Apelação Criminal 1501099-78.2020.8.26.0567; Relator (a): Fernando Torres Garcia; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Sorocaba - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 15/02/2021; Data de Registro: 15/02/2021)

APELAÇÃO - Tráfico ilícito de drogas, dano qualificado e resistência em concurso material - Autoria e Materialidade comprovadas - Palavra dos Policiais Militares - Validade - Precedentes - Circunstâncias fáticas que demonstram o comércio ilícito de drogas realizado pelo réu - Laudos periciais corroborando a ocorrência dos delitos de resistência e dano qualificado - Incabível a alegação de insuficiência probatória - Pena - Dosimetria - Pleito de reconhecimento do redutor - Atendimento - Impossibilidade - Circunstâncias do caso concreto que indicam que o acusado se dedicava a atividades criminosas, no caso, ao tráfico habitual de drogas - Penas de todos os delitos fixadas de maneira apropriada - APELO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 1501890-92.2018.8.26.0510; Relator (a): Silmar Fernandes; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Rio Claro - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 15/02/2021; Data de Registro: 15/02/2021).

Não se pode negar valia aos depoimentos dados pelos policiais nestes autos, pois, repita-se, produzidos de forma segura e extreme de dúvidas.

Como já dito, não há sequer sugestão de que tivessem eles o mínimo interesse em incriminar o acusado injustamente, mormente diante do notório risco de eventual responsabilidade pelo crime de abuso de autoridade ou de denúncia caluniosa. Frise-se que, por importante, a conduta do réu atingia diretamente o adolescente Igor, seu cúmplice no crime, situação essa que configura a majorante prevista no inciso VI, do artigo 40 da lei especial.

O relato do acusado encontra-se isolado no contexto probatório com o qual, aliás, colide frontalmente. O réu não apresentou em juízo qualquer testemunha que pudesse confirmar sua narrativa.

Ante o exposto, conclui-se que o contexto probatório é harmônico e coerente; robusto o bastante a embasar a expedição de um édito condenatório.

O réu realizou conduta antijurídica que se subsume em tipo penal e, ante a sua culpabilidade, impõe-se a condenação e a pena que passo a dosar, eis que em seu benefício não militam quaisquer justificativas ou dirimentes.

DOSIMETRIA

Prevê o art. 68 do Código Penal que a pena base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste código (circunstâncias judiciais); em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes (art. 65) e agravantes (arts. 61 e 62); por último, as causas de diminuição e de aumento, entendidas estas últimas como sendo os fatores de acréscimo ou redução da pena, assinalados em quantidades fixas (dobro, metade etc) ou em limites (um a dois terços etc), previstos na parte geral ou especial do Cód. Penal (cf. Código Penal Comentado, Celso Delmanto, 2ª ed. Renovar, p.120).

Já o art. 59 dispõe que o Juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime: as penas aplicáveis dentre as cominadas; a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos; o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade e a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.

Prevê o artigo 42 da Lei nº. 11.343/06: O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a

quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

O réu não possui antecedentes (fl. 57).

Sua culpabilidade, entendida como índice de reprovabilidade de sua conduta, no caso, é de média intensidade.

Sua personalidade e conduta social não de ser tidos por média intensidade.

Atento, ainda, ao motivo do delito - qual seja, o ânimo de auferir lucro, já que se dispôs a trazer a droga no meio da rua - bem como, atento às circunstâncias e funestas consequências da infração, que degrada a pessoa e compromete o tecido social e, em especial, considerando a grande quantidade de substâncias entorpecentes que o acusado trazia consigo, com os malefícios de todos conhecidos, fixo a pena base 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal chegando a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa.

Embora praticado durante a Pandemia de Covid-19, tal circunstância em nada contribuiu para a realização do delito. Não há nos autos provas de que o acusado se valeu das facilidades decorrentes da situação enfrentada pelo mundo para o cometimento do crime. É fato que a pandemia não facilitou a prática do delito, tampouco agravou seus efeitos. A traficância ocorre em um mesmo grau, faça chuva ou faça sol, em situações pandêmicas ou não. É um câncer que a sociedade enfrenta, infelizmente, sem expectativa de cura num futuro próximo.

No sentido de afastamento da agravante, colaciono jurisprudência:

Cerceamento de defesa - Inversão da ordem de oitivas - Ausência de formalidade processual - Ampla Defesa plenamente exercida - Ausência de comprovação de prejuízo - Preliminar rejeitada. Tráfico de Drogas - Insuficiência probatória - Absolvição ou desclassificação para artigo 28 da Lei 11.343/06 - Inadmissibilidade - Materialidade e autoria suficientemente demonstradas - Condenações mantidas - Recursos não providos. Redução da reprimenda - Segunda fase da dosimetria - Apelantes não se prevaleceram das fragilidades causadas pela pandemia - Majorantes de calamidade pública afastadas -- Recursos providos para este fim. Confissão espontânea - Súmula 545/STJ - Utilizada para a formação do convencimento - Reconhecida a atenuante - Recurso provido para este fim. Tráfico privilegiado - Possibilidade - Primárias, diminuta quantidade de entorpecente e sem comprovação de envolvimento com o meio ilícito - Redutor aplicado para Larissa e Ingrid - Recursos providos para este fim. Regime aberto e substituição das penas privativas de liberdade por restritiva de direitos - Possibilidade - Requisitos do artigo 44 do Código Penal preenchidos por Larissa e Ingrid - Recursos providos para este fim. Regime menos gravoso - Impossibilidade - Binômio da reprovabilidade da conduta e suficiência das sanções impostas - Inicial fechado adequado à gravidade concreta do delito e às circunstâncias pessoais do agente - Recurso de Caio não provido. (TJSP; Apelação Criminal 1500858-92.2020.8.26.0571; Relator (a): Klaus Marouelli Arroyo; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Tatuí - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/01/2021; Data de Registro: 14/01/2021) (grifo meu)

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 C/C ART. 40, I E V, DA LEI Nº 11.343/2006. MÉRITO. MATERIALIDADE. AUTORIA E DOLO. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO CRIME. AGRAVANTE. CALAMIDADE PÚBLICA. NÃO INCIDÊNCIA. INTERESTADUALIDADE. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. . MÉRITO: Configurados a materialidade, autoria e dolo do agente no delito insculpido no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 40, inciso I, do mesmo diploma legal, o desfecho condenatório é de rigor. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO CRIME. PERSONALIDADE DO AGENTE: Conforme o entendimento firmado no âmbito do STJ, a prática de ato infracional não justifica a exasperação da pena-base, por não configurar infração penal, não podendo, portanto, ser valorada negativamente na apuração da vida pregressa do réu a título de antecedentes, personalidade ou conduta social; . CONDUTA SOCIAL: A propósito, a circunstância judicial conduta social, prevista no art. 59 do CP, compreende o comportamento do

agente no meio familiar, no ambiente de trabalho e no relacionamento com outros indivíduos, configurando antecedentes sociais, os quais não se confundem com os seus antecedentes criminais. Ou seja, trata-se do estilo de vida do réu, correto ou inadequado, perante a sociedade, desassociado da noção de antecedentes criminais. De modo que a sua valoração negativa exige concreta demonstração de desvio da natureza comportamental; . CONFISSÃO ESPONTÂNEA: O reconhecimento da atenuante genérica prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal exige que o réu confesse os fatos pelos quais está sendo devidamente processado; . CALAMIDADE PÚBLICA: Não é suficiente a vigência do Decreto que reconheceu estado de calamidade pública, ocasionado pela pandemia do Covid-19, para a incidência da agravante do art. 61, II, 'j', do Código Penal. O agravamento da pena exige a existência de situação concreta dando conta que o réu se prevaleceu da pandemia, que justificou o Decreto, para a prática do tráfico de drogas, situação não verificada no caso concreto; . CAUSA DE AUMENTO. INTERESTADUALIDADE: Para caracterização da causa de aumento descrita no inciso V do artigo 40 da Lei nº 11.343/06, faz-se necessário comprovar que a droga provém de outro Estado ou que se trata de tráfico entre Estado e Distrito Federal, não bastando simplesmente que o agente transponha ou pretenda transpor os limites de uma ou mais Unidades da Federação, até chegar ao seu destino final. No caso, não é possível averiguar a prática de tráfico entre Estados e, sim, apenas que a droga tinha como destino o Estado de São Paulo ou do Ceará. Mantida apenas a transnacionalidade do delito; . CAUSA DE DIMINUIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO: Para a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, o condenado deve preencher cumulativamente todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa. O legislador objetivou possibilitar a redução de pena para aquele considerado como pequeno traficante eventual, ou seja, que não faz do crime seu meio de vida. Os requisitos são cumulativos, e, na ausência de um deles, afasta-se a incidência do dispositivo; . No caso, as circunstâncias dos autos, tomadas em seu conjunto, traduzem indicativos de que o réu integra grupo criminoso e se dedica à atividade delitiva, de modo que a causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 não tem lugar como redutor de pena. (TRF4, ACR 5001996-93.2020.4.04.7017, SÉTIMA TURMA, Relator GUILHERME BELTRAMI, juntado aos autos em 10/03/2021) (grifo meu)

Uma vez que a conduta abrangeu o adolescente Igor (art. 40, VI), aumento a pena anterior em 1/6 (um sexto), chegando-se a pena de 6 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais pagamento de 680 (seiscentos e oitenta dias multa).

O acusado faz jus à causa de diminuição prevista no parágrafo 4º, do artigo 33 da nova lei de entorpecentes, eis que é primário e possui bons antecedentes, devendo sua pena ser reduzida no patamar de 1/2 (metade), chegando-se a pena final de 3 (três) anos, 04 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, mais pagamento de 340 (trezentos e quarenta) dias multa, a qual torno definitiva na ausência de outras modificadoras.

Entende este juízo que, embora grande a quantidade de droga, não há qualquer outra prova nos autos que o acusado faça parte de organização criminosa ou exerça o ilícito habitualmente, razão pela qual o redutor deve ser aplicado, porém em grau intermediário.

Neste sentido:

Apelação. Tráfico ilícito de entorpecentes majorado (artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06). Sentença condenatória. Defesa apela referendo a absolvição e o direito de apelar em liberdade. Autoria e materialidade devidamente fundamentadas. Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar o dolo da mercancia da ré. Confissão judicial corroborada pelos depoimentos dos policiais. Manutenção da condenação. Dosimetria comporta reparo. Basilar deve retornar ao mínimo legal. Confissão reconhecida, contudo, sem reflexo na pena. Súmula 231 do C. STJ. Reconhecimento do redutor previsto no § 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas. Quantidade que, por si só, não afasta a aplicação do

reductor. Ré primária. Não comprovação de envolvimento com atividades criminosas ou organização criminosa. Quantidade a impedir, todavia, a redução no patamar máximo, mostrando-se ajustada a redução de metade. Abrandamento do regime prisional para o aberto. Pena corporal substituída por restritiva de direitos. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.(TJSP; Apelação Criminal 1500680-42.2019.8.26.0616; Relator (a): Osni Pereira; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Suzano - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 18/02/2021; Data de Registro: 18/02/2021)

APELAÇÃO. Tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Recursos defensivo e ministerial. Insuficiência probatória. Não ocorrência. Autoria e materialidade bem demonstradas. Desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/06. Inviabilidade. Circunstâncias da prisão e quantidade de droga incompatíveis com a alegação de posse de drogas para consumo pessoal. Condenação confirmada. Dosimetria. Pena imposta pelo crime de posse irregular de arma de fogo corretamente mantida no piso. Pena-base relativa ao crime de tráfico fixada acima do mínimo legal. Quantidade da droga que deve ser considerada para aferição do reductor. Redução de rigor. Apelante primário, preso com quantidade de drogas não excessiva, sem demonstração de que se dedique a atividades ilícitas ou que pertença a organização criminosa. Circunstâncias favoráveis. Possibilidade de aplicação do reductor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, em seu grau intermediário, em face da quantidade e variedade das drogas, com fixação de regime aberto para o início do cumprimento da pena e conversão da pena privativa de liberdade em penas restritivas de direitos. Pretensão da concessão do direito de recorrer em liberdade prejudicada. Recurso ministerial improvido e recurso da Defesa parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 1500411-86.2020.8.26.0286; Relator (a): Leme Garcia; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itu - 1ª Vara Criminal e de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; Data do Julgamento: 16/02/2021; Data de Registro: 16/02/2021)

Ainda, no que diz respeito ao fator de redução, não há violação ao princípio do bis in idem, quando este subscritor utilizou-se da mesma regra – quantidade e natureza da droga – para dosar a redução em ½ (metade), haja vista ter se utilizado da mesma fundamentação em finalidades e momentos diferentes. Nestes termos:

Tráfico de entorpecentes e Associação para o tráfico –Agentes surpreendidos trazendo consigo, para fins de tráfico, 3.026,50 gramas de cocaína em pó e 1.448,7 gramas de maconha – Conjunto probatório desfavorável aos réus alicerçado em depoimentos policiais verossímeis demonstrando tanto o tráfico como a união estável e duradoura entre os acusados para a prática de tráfico – Descabimento da causa de redução prevista no § 4º, do art. 33 Lei n. 11.343/06 Ainda que as investigações tenham se iniciado em razão de meras denúncias anônimas, a condenação, tanto pelo crime de tráfico, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06, como pelo de associação para o tráfico, descrito no art. 35 do mesmo estatuto repressivo, será de rigor, sempre que o conjunto probatório, alicerçado em depoimentos policiais verossímeis, demonstre de modo efetivo, não apenas a existência do tráfico ilícito de entorpecentes, como de que este foi antecedido pela união estável e duradoura entre os acusados voltada para sua prática. Em tal situação é, ainda, incabível a incidência da causa de redução prevista no § 4º, do art. 33 do referido diploma legal, por incompatibilidade lógica, uma vez que a associação para o tráfico denota, com efeito, o envolvimento do agente com atividades criminosas e a integração de organização criminosa, aspectos que afastam a incidência da referida causa especial de diminuição de pena. Cálculo da Pena – Tráfico de entorpecentes – Quantidade e variedade de substância tóxica apreendida indicativa de maior potencial nocivo da conduta do agente – Circunstância objetiva que deve pesar tanto para majorar a pena-base como para simultaneamente justificar aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 em percentual abaixo do máximo – Inexistência de bis in idem O art. 42 da Lei n. 11.343/2006 determina que,

na dosimetria da pena, sejam sempre considerados tanto a natureza e a quantidade de entorpecente, quanto a personalidade e a conduta social do agente. A incidência do primeiro fator mencionado, de ordem qualitativa e quantitativa, não só pode - como deve - ocorrer, tanto na primeira fase do cálculo da pena, como também cumulativamente na terceira, na qual será fixado o percentual de eventual redução, na hipótese de estarem presentes os requisitos do art. 33, § 4º, do mesmo diploma legal. Assim, ainda que a pena-base já tenha sido majorada com lastro na quantidade e na variedade do tóxico apreendido, poderá perfeitamente o Magistrado, com base no mesmo fundamento, deixar de aplicar o redutor em seu máximo, e estabelece-lo em patamar mínimo ou intermediário, sem que tal proceder implique em bis in idem; isso porque referido elemento qualitativo e quantitativo será necessariamente apreciado em cada fase do cálculo sob perspectivas completamente distintas. Na primeira fase, a quantidade e a variedade da substância apreendida devem ser consideradas, com efeito, enquanto parâmetro para a constatação da intensidade de lesão à saúde pública; na terceira, enquanto fator de aferição do grau de envolvimento do réu com a criminalidade organizada ou de sua devoção à atividade criminosa. (TJSP; Apelação Criminal 0012004-89.2018.8.26.0050; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 21ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 29/01/2021; Data de Registro: 29/01/2021)

Cada dia multa fica fixado no valor mínimo previsto na lei especial, dada a pouca fortuna do réu, dado que emerge dos autos.
Atento a primariedade do acusado, além da quantidade de pena imposta, fixo o regime aberto para cumprimento de pena.
Anoto que, este posicionamento, neste caso, partiu da necessidade de proporcionar ao réu uma nova oportunidade, pois não adianta somente castigar o indivíduo; retirá-lo do convívio da sociedade e de seus familiares, da possibilidade de conseguir sustentar-se e encarcerá-lo novamente gerará uma revolta; a descrença na justiça será enorme; sua não reinserção na sociedade fará com que acabe praticando novas infrações e, atolando ainda mais o sistema carcerário.
DECISÃO.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA DEDUZIDA EM JUÍZO e o faço para declarar Luiz Henrique Duarte Barbosa, qualificado nos autos na fl. 21, incurso no artigo 33, caput, c.c. parágrafo 4º, c.c. artigo 40, inciso VI, todos da Lei 11.343/06, razão pela qual o CONDENO ao cumprimento da pena de 3 (três) anos, 04 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, mais pagamento de 340 (trezentos e quarenta) dias multa , cada qual no valor mínimo legal, ante a pouca fortuna do condenado, dado emergente dos autos.
Preenchendo o acusado os requisitos do artigo 43 e seguintes do Código Penal, converto sua pena privativa de liberdade em duas restritivas de direitos, quais sejam, uma prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas a critério do Juízo das Execuções Criminais, mais pagamento de 10 (dez) dias multa.
Neste sentido:

APELAÇÃO - Tráfico de drogas - Apelo do Ministério Público desprovido - Quantidade de entorpecente apreendida que não pode ser considerada expressiva, razão pela qual a pena-base deve ser mantida no mínimo legal - Ausente prova de que o réu se dedique às atividades criminosas ou integre organização criminosa - Cabível o reconhecimento do chamado tráfico privilegiado, com a redução da pena, em sua fração máxima (2/3), nos termos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 - Viável a substituição da reclusiva por duas penas alternativas, consistentes em prestação de serviços comunitários e outra multa - Também deve ser modificado o regime inicial para o aberto, nos termos do art. 33, § 2º, "c", do CP - Precedentes do C. STJ e do E. STF - APELO DO MP DESPROVIDO - RECURSO DEFENSIVO PROVIDO para reduzir as penas a 01 ano e 08 meses de reclusão, além de 166 dias-multa, bem como para modificar o regime para o aberto, substituindo-se a reclusiva por penas restritivas de direitos - Expeça-se, com urgência, alvará de soltura clausulado. (TJSP; Apelação Criminal 1500317-90.2018.8.26.0551; Relator (a): Osni Pereira; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Limeira - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento:

10/07/2020; Data de Registro: 10/07/2020)

Tráfico de drogas. Conduta de trazer consigo, expor à venda e guardar 46 porções de cocaína. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Pretendida absolvição. Inadmissibilidade. Depoimentos de policiais militares que efetuaram a prisão. Usuário surpreendido no momento da abordagem que afirmou ter adquirido entorpecente do réu. Validade e suficiência para a procedência da ação penal. Circunstâncias da prisão e modo de acondicionamento indicativos do intuito mercantil. Condenação mantida. PENA. Majorante referente à proximidade de igrejas e estabelecimentos de ensino que não pode ser mantida. Absoluta ausência de indicativos no sentido de que a traficância colocava em risco os seus frequentadores. Redução para 1 ano e 8 meses de reclusão, e 166 dias-multa. Substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos. Admissibilidade. Inconstitucionalidade das vedações da Lei 11.343/06. Violação ao princípio da individualização da pena (art. 5º, inciso XLVI, da CF). Precedentes do STF e do STJ. Conversão da pena reclusiva em restritivas de direitos: prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária. Inteligência do artigo 44, § 2º, parte final, do CP. Imposição do regime aberto. Apelo defensivo parcialmente provido para esse fim. (TJSP; Apelação Criminal 0000271-94.2017.8.26.0557; Relator (a): Otávio de Almeida Toledo; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Barretos - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/07/2020; Data de Registro: 08/07/2020)

Nos termos do artigo 63, caput e §1º, da Lei 11.343/2.006, determino, se for o caso, o perdimento do valor apreendido em favor da União.

Deixo de determinar o lançamento do nome do réu no rol dos culpados, ante a revogação do artigo 393, do Código de Processo Penal.

Nos termos do artigo 72 da Lei 11.343/06, determino a destruição das drogas armazenadas para contraprova, no prazo máximo de 30 dias, devendo a autoridade policial enviar termo da incineração.

Por fim, condeno o réu ao pagamento das custas processuais em seu mínimo legal (Lei Estadual de Custas), pois se encontra assistido por defensor constituído, presumindo-se, assim, relativa capacidade econômica para arcar com tal finalidade.

P . I . C .

São Paulo, 9 de março de 2022.

Fernando Augusto Andrade Conceição
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006.